

1500530-38.2020.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/12/2022

... informações de que Bruno estaria realizando tráfico; que como Bruno estava sendo investigado por roubo, a polícia civil deu preferência à expedição de mandado de roubo, mas que Bruno também era investigado por tráfico e que a polícia pretendia continuar, posteriormente, investigando o tráfico mas que no dia calhou de ocorrer o cumprimento do mandado de busca e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

1ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital-SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500530-38.2020.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500530-38.2020.8.26.0580

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323217/2020 - DEL.POL.PLATINA, 15421937 - DEL.POL.PLATINA, 72/20/114 - DEL.POL.PLATINA, 2323217 - DEL.POL.PLATINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Vinicius de Queiroz Lourenço e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU

Vistos.

MARCOS VINICIUS DE QUEIROZ LOURENÇO, NALANDA GOMES ALVES DE LIMA e BRUNO CESAR DE ANDRADE, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.

11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal (denúncia às fls. 180/182).

Consta na peça acusatória que, no dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 18h20, na Rua João de Souza Martins, nº705, Vila Dos Ypês, na Cidade de Platina, nesta Comarca de Palmital-SP, MARCOS VINÍCIUS DE QUEIROZ LOURENÇO, NALANDA GOMES ALVES DE LIMA e BRUNO CESAR DE ANDRADE, qualificados, respectivamente, às fls. 39, 49 e 59, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela identidade de propósitos e unidade de desígnios entres eles e o adolescente, Luís Felipe Queiroz Lourenço, traziam consigo e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 65 (sessenta e cinco) invólucros contendo maconha, com peso total de aproximadamente 501,54g e peso líquido de 487,06g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/27, laudo de constatação provisória de fls. 36/38, fotografias de fls. 28/33 e laudo definitivo de fls. 170/172, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante no dia 29.12.2020 (fls. 1/2).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 107/110).

Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia (fls. 239/242 - MARCOS, fls. 315/326 - NALANDA e fls. 346/351 - BRUNO)

A denúncia foi recebida em 30.04.2021 (fls. 395/397).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Leonardo Isaac Pelegrini da Silva, Reginaldo Pinheiro, Wanderson Maximilian Ortiz Albuquerque, Gideão Cirino de Camargo e Clodoaldo Caetano de Camargo, sobrevivendo o interrogatório dos réus (fl. 429).

Na sequência, encerrada a fase instrutória, a Promotoria ofertou alegações finais, bem como foi concedida liberdade provisória aos réus MARCOS e NALANDA (fls. 422/423).

O órgão ministerial apresentou alegações de forma oral, requerendo a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

As defesas, por sua vez, apresentaram alegações por meio de memoriais.

Bruno Cesar de Andrade defendeu sua absolvição ou, subsidiariamente, que não seja reconhecido como reincidente, tampouco específico, sendo em caso de condenação beneficiado com a figura do tráfico privilegiado (fls. 448/453). Marcos Vinicius de Queiroz Lourenço, por sua vez, argumentou a inexistência de prova de que estaria realizando a traficância, pugnando por sua absolvição, apontando, ainda, seus bons antecedentes, possuir trabalho lícito e residência fixa (fls. 454/459). Por fim, a defesa de Nalanda Gomes Alves de Lima pugna por sua absolvição por ausência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo (fls. 465/469).

As fls. 473/475 há pedido de restituição dos celulares apreendidos.

A sentença foi proferida em 23.07.2021 (fls. 478/489).

Apresentadas razões recursais pelo Ministério Público às fls. 494/505, pela ré NALANDA às fls. 522/528, pelo réu BRUNO às fls. 589/593, bem como contrarrazões (fls. 529/539 - MARCOS, fls. 540/545 - NALANDA, fls. 594/596 - BRUNO, fls. 600/601 - MINISTÉRIO PÚBLICO).

A sentença foi anulada, nos termos do acórdão de fls. 631/635.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 17/21); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/27), laudo pericial de constatação prévia (fls. 36/38); laudo pericial definitivo (fls. 170/172); pelo laudo de objetos (fls. 166/168); pelos termos de depoimentos e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, analisa-se, adiante, a prova produzida.

A testemunha Leonardo Isaac Pelegrini da Silva, devidamente compromissada, policial civil, afirmou que participou da ocorrência, que no dia dos fatos estava na delegacia de Platina, onde é investigador; que Bruno vinha sendo investigado por outro crime; que estava aguardando mandado de prisão temporária em razão das suspeitas de roubos; que estava no aguardo do deferimento e da expedição do mandado de prisão temporária; que a casa de Bruno é próxima à delegacia; que por volta das 17:00 estava em campana e havia solicitado reforço da Polícia Militar para cumprimento do mandado; que viram na frente da casa movimentação típica de tráfico; que nesse dia verificou a movimentação; com a chegada dos policiais militares houve correria, sendo que olheiros e compradores correram; que o depoente deteve uma dessas pessoas após correr; que o levou para dentro da casa; que um dos policiais militares alcançou outro indivíduo; que um indivíduo correu para dentro da casa e estava com porções grandes de maconha; que no quarto estavam Bruno e Nalanda cortando e embalando as drogas; que o restante foi relatado pela polícia militar que foi quem adentrou à casa; que a visualização ocorreu inicialmente da própria delegacia, vendo pessoas entrando e saindo, atitude típica de tráfico; que iniciou a campana por volta das 16:50; que a PM chegou as 18:10 horas e que as 18:20 horas fizeram a abordagem; que havia olheiros no local, um deles era Marcos Vinicius; que usuários chegavam e ficavam na frente da casa; que ora Bruno e ora Marcos Vinicius entravam na casa e voltavam entregando algo às pessoas; que Bruno saiu

umas três vezes de bicicleta e que nessas vezes Marcos Vinicius é quem ficava na frente da residência; que o indivíduo que o depoente apanhou inicialmente negou mas depois admitiu ter ido ao local comprar drogas; disse que fugiu porque ao ver a polícia teve medo; que populares nas redondezas passavam informações de que Bruno estaria realizando tráfico; que como Bruno estava sendo investigado por roubo, a polícia civil deu preferência à expedição de mandado de roubo, mas que Bruno também era investigado por tráfico e que a polícia pretendia continuar, posteriormente, investigando o tráfico mas que no dia calhou de ocorrer o cumprimento do mandado de busca e apreensão e conseguiram elementos da traficância; que o depoente já havia investigado Marcos por tráfico, mas que a investigação não demonstrou a traficância; que conhece o menor de idade, irmão de Marcos, apreendido no dia; que no dia viu o adolescente; que o adolescente estava do lado de fora da casa; que não se recorda de ter visto Marcos conversando com o irmão; que o depoente não entrou na casa; que viu Bruno do lado de fora.

O policial militar Wanderson Maximilian Ortiz Albuquerque, compromissado, afirmou que no dia dos fatos prestou apoio à polícia civil; que o investigador Leonardo havia pedido o apoio; que ele estava aguardando o mandado de prisão temporária; que como o investigador estava aguardando para cumprimento do mandado viu a movimentação típica do tráfico; que os policiais foram até Platina cumprirem o mandado; que estava dirigindo a viatura; que os demais policiais adentraram a residência; que abordou Luis Felipe (adolescente); que os demais policiais acompanharam Marcos Vinicius que estava tentando guardar um invólucro com porções embaladas para venda; que no quarto estavam Bruno e Nalanda fazendo a pesagem e embalando outras drogas; que foram achadas duas facas utilizadas para fracionar as drogas; que o depoente foi o responsável pela apreensão do adolescente; que ele é irmão do Marcos Vinicius; que pararam a viatura em lugar próximo; que os policiais desembarcaram e eles correram cada um para um sentido, mas como estavam em vários policiais conseguiram capturar todos; que os irmãos já são conhecidos pelo tráfico; que posteriormente entrou na casa para ver a situação; que não realizou a abordagem dos réus; que com o adolescente não encontrou nada ilegal, tampouco apetrechos que indicassem o uso; que até onde sabe o adolescente não é usuário de drogas; que as informações que têm dizem que Bruno seria o 'patrão' do tráfico e os demais seus auxiliares; que ao chegar ao local viram os três correndo: Thiago (usuário), Luis Felipe e Marcos Vinicius, e cada policial foi atrás de um deles.

O policial militar Reginaldo Pinheiro, compromissado, afirmou que no dia dos fatos foram auxiliar o cumprimento de um mandado de prisão e que o investigador responsável enquanto aguardava verificou movimentação típica de tráfico; que o depoente entrou na casa; que Marcos correu para a cozinha; que ele tentava esconder o pacote no armário; que na passagem viram Bruno e Nalanda no quarto; que apreenderam Marcos e o levaram para o quarto; que encontraram com Marcos R\$100,00 em espécie, com Bruno R\$279,00, além do entorpecente e da balança de precisão; que os acusados nada disseram; que a casa era pequena com 4 cômodos, dois quartos, sala e cozinha; que o depoente é supervisor; que roda sete cidades da região e por isso geralmente não conhece a fundo quem realiza o tráfico, o que sabe é de informações prestadas; que quando chegou viu Marcus Vinicius com um pacote na mão, no portão, conversando com duas pessoas, uma deles o seu irmão, o pacote tinha o tamanho de um pacote de as ou um pouco menor; que só viu o externo do pacote; que foi o depoente quem foi atrás de Marcos; que ao adentrar a casa viu ele fechando a porta do armário; que pela segurança da equipe Marcos foi levado para permanecer junto com os demais acusados no quarto; que após a abordagem retornou e viu que o pacote guardado por Marcos continha 18 porções maiores de entorpecentes; que dentro do armário tinha alguns mantimentos; que a única sacola no armário era aquela, por isso presume que era a mesma que Marcus segurava.

Gideão Cirino de Camargo e Clodoaldo Caetano de Camargo testemunhas abonatórias atestaram a idoneidade de Marcus Vinicius.

Em interrogatório, foram ouvidos os três réus.

Nalanda Gomes Alves de Lima em sua defesa diz que já namorou e morou com Bruno; que há três meses tinham terminado; que estava trabalhando em Assis; que voltaram a conversar e no dia dos fatos ela tinha resolvido ir vê-lo; que no dia dos fatos ela

acordou com o barulho dos policiais; que como havia acabado de acordar não sabe dizer o que Bruno estava fazendo, mas que nada sabe a respeito das drogas e não tem ligação com elas.

Bruno César de Andrade em seu interrogatório afirmou que havia sido inocentado de um roubo recentemente; que não sabe dizer de onde veio a droga; que tinha apenas um 'baseado'; que não tem conhecimento do meio quilo de maconha; que tinha sido preso injustamente; que os policiais teriam o ameaçado; que já teve problemas com os policiais, pois eles queriam que ele assumisse uma droga; que os policiais estariam com rancor em relação a ele. Perguntado pela acusação porque a versão dada em audiência era distinta daquela nos autos, disse que assumiu em delegacia a propriedade da droga porque foi torturado pela polícia militar; que não foi realizada perícia médica nele; que faz uso de maconha e já usou cocaína.

Marcos Vinicius de Queiroz Lourenço em seu interrogatório disse que no dia dos fatos não foi trabalhar e que estava passando numa rua próxima a sua casa e encontrou seu irmão; que pediu ao irmão que fosse para a casa da família; que nisso entrou na casa do Bruno; que trouxe um cigarro de maconha; que pegou um certo 'negócio' e estava saindo quando os policiais o abordaram; que os policiais perguntaram o que ele estava fazendo; que relatou aos policiais que tinha encontrado "Lulinha" (Bruno) a tarde na cidade e que ele sabia que o interrogado estava sem cigarro de maconha e que combinaram de ele ir na casa de Bruno mais tarde; que chegou na casa de Bruno e ele tinha duas 'parangas' e deu uma para o interrogado; que os policiais perguntaram do dinheiro que ele estava carregando e que disse a eles tratar-se de dinheiro oriundo de seu trabalho; que quando viu estava na delegacia; que tinha cem reais e tinha pego um 'vale' do seu patrão; que ajuda o pai em casa por ser o filho mais velho.

Embora tenham negado os fatos, a versão dada pelos acusados não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foram incapazes de infirmar o restante do contexto probatório, que lhes é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Os depoimentos dos policiais possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste Juízo. Vale destacar que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Ademais, em relação à idoneidade do testemunho dos policiais, não é possível simplesmente descartar a prova sob o pretexto de que os agentes possuem interesse na condenação do acusado. Isso porque, devidamente compromissados nos termos da lei, cientes de que poderiam responder por crime de falso testemunho, relataram a dinâmica dos fatos tal qual se deu. Nesse sentido, a defesa não conseguiu trazer qualquer elemento aos autos que pudesse infirmar o testemunho dos policiais; nada existe a indicar que os policiais estivessem perseguindo os réus, ou que tivessem

qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

No caso dos autos, tem-se que houve campana anterior realizada pela polícia, que verificou que os acusados estavam mantendo em depósito a droga apreendida e que ao mesmo tempo realizavam seu comércio, sendo que o réu Marcos Vinicius atuou como 'aviãozinho' algumas vezes, nome popular dado àqueles que permanecem vigiando o ponto de tráfico enquanto os demais promovem a venda. Além disso, a sacola que estava com Marcos continha droga e Bruno e Nalanda foram vistos pelos policiais embalando referidos entorpecentes.

A versão dos acusados, desta forma, não se sustenta ante a prova amealhada, não havendo no caso razões para se colocar em dúvida a palavra dos agentes de segurança.

Cabe mencionar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga e comportamento do réu logo antes ou no momento da apreensão, bem como a apreensão de valores em poder do réu sem a comprovação de origem idônea, sendo até desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.

Nesse sentido: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Acerca do envolvimento do menor Luis Felipe, a testemunha Thiago Alves de Lima Lemes, ouvida na delegacia, afirmou que, na data dos fatos, entregou R\$5,00 para o menor Luis Felipe e pediu que este pegasse a droga, momento que as viaturas chegaram ao local (fl. 7). Ainda, há o depoimento de um dos réus, também indicando a presença do menor Luis Felipe na atividade criminosa: "que no final desta tarde, foi até a casa de BRUNO CESAR comprar drogas, sendo que quando chegou, na frente da casa estava seu irmão LUIS FELIPE, sendo que entrou para dentro da casa" (fl. 10). Por fim, embora tenha negado o envolvimento deles, o réu BRUNO admitiu que "MARCOS VINICIUS e LUIS FELIPE, que são irmãos, conhece da "rua", e sempre vão em sua casa. Afirma que MARCOS VINICIUS e LUIS FELIPE são usuários de drogas." (fl. 14), isto é, o menor frequentava a residência, com finalidades criminosas, versão que corrobora a já fornecida pelos policiais com relação ao envolvimento do menor Luis Felipe na traficância, inclusive este foi abordado e apreendido no local da ocorrência.

Restou indubitosa a presença e participação do adolescente na empreitada.

Diante disso, comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 33, "caput", c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, e não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade da ré, é de rigor a condenação.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, primeiramente analiso o art. 42, da Lei 11.343/2006, cuja redação prevê que a natureza e a quantidade da substância devem ser analisadas com preponderância em relação às circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, a natureza da droga apreendida não indica maior reprovabilidade da conduta dos acusados, não havendo, assim, a meu juízo, motivação para exasperação da pena mínima. Quanto à quantidade, ainda que não seja ínfima, tampouco se mostra elevada a ponto de justificar a majoração da pena.

Ultrapassada a etapa do art. 42, da Lei 11.343/2006, passo a análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e verifico que não há razões para exasperar a penalidade.

Desta forma, mantenho a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, embora os réus Nalanda e Marcos Vinicius façam jus à atenuante da menoridade, não se pode abaixar a pena abaixo do mínimo legal, conforme prevê a Súmula 231, STJ. Por sua vez, o réu Bruno é reincidente conforme certidões de fls. 78/82, devendo a pena ser aumentada em 1/6 em razão da reincidência.

Desta forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena base para os réus Nalanda e Marcos Vinicius, e exaspero em 1/6 em relação ao réu Bruno, fixando a reprimenda nessa fase em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. No caso em tela, os réus Nalanda e a Marcos Vinicius, são ambos primários, sem antecedentes criminais, não havendo qualquer indicativo de reiteração criminosa ou de dedicação a organizações criminais, perfazendo, assim, exatamente o traficante a quem a lei optou por beneficiar, ou seja, aquele “de primeira viagem”. Nesse sentido, é dado ao julgador utilizar a quantidade da droga para fins de fixação da fração de diminuição, pois ainda que se trate de traficante “de primeira viagem”, a conduta de praticar o tráfico com uma quantidade maior de droga deve ser mais duramente apenada em relação ao traficante apanhado com pequena porção de droga. De modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no mencionado dispositivo legal, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, autorizam a redução da pena no percentual máximo de 2/3 (dois terços), razão pelo qual diminuo a pena em 3 anos e 4 meses reclusão e 333 dias-multa, passando a dosá-la em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

A esse respeito, consigno passagem do voto do Ministro Gilmar Mendes nos autos do “Habeas Corpus” nº 154694 AgR/SP: “(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.

Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena”. (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50). E também: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)”. (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. (...)” (STF. 2ª Turma. HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/2/2020 (Info 965)

Já no que se refere ao réu Bruno, inviável a aplicação do referido redutor. Isso porque se trata de acusado reincidente, muito embora não específico, corrigindo essa magistrada o quanto posto no termo de audiência. Em que pesa a reincidência não seja específica, o tipo penal do art. 33, §3º, da Lei de Drogas não se assemelha ao tipo do art. 28, posto que neste o agente está a prejudicar sua saúde (daí a tese de que seria inconstitucional por violar o princípio da lesividade), e naquele coloca em risco a vida de outrem. Contudo, o acusado também possui condenação pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas que, muito embora não tenha transitado em julgado, serve de elemento a demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas.

Sobre a possibilidade de utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para formação de convencimento em relação à figura do tráfico privilegiado, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, veja-se: “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016. Info 596)”.

Por fim, há a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n.

11.343/06, a qual ficou devidamente demonstrada, tanto em sede policial como em juízo, autorizando o aumento de pena de um sexto a dois terços. No caso concreto, entendendo cabível o aumento em seu patamar mínimo, tendo em vista que o envolvimento do adolescente, também, mostrou-se mínimo, isto é, avisava BRUNO sobre a presença de "clientes" ou de policiais, bem como frequentava o local para fazer uso da droga.

Assim, aumento a pena dos três réus em 1/6 (um sexto).

Dessa forma, em relação ao réu Bruno Cesar de Andrade, fixo a pena final em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em relação à Nalanda Gomes Alves de Lima e Marcos Vinicius de Queiroz Lourenço fixo a pena final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Para Nalanda Gomes Alves de Lima e de Marcos Vinicius de Queiroz Lourenço o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve ser o ABERTO, orientado pelo quantum de pena cominado. Neste tópico, certo é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Do mesmo modo é entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APELAÇÃO JULGADA. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. ILEGALIDADE MANIFESTA. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO" (HC 227834 / DF, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 26/08/13).

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o legislador estabeleceu, no artigo 44 do Código Penal, critérios para orientar a avaliação sobre a necessidade e suficiência da substituição. Pode ser substituída a pena de crime culposo, independentemente do quantum fixado, e a pena do delito doloso, desde que não superior a quatro anos e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, o réu não pode ser reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a sua personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime devem indicar que a substituição é suficiente.

No caso dos autos, a substituição ou a concessão de sursis não são possíveis, uma vez que o envolvimento de adolescente na traficância demonstra maior gravidade, bem como circunstância que indica não ser a substituição ou o sursis repressões suficientes ou proporcionais.

Em relação a Bruno Cesar de Andrade o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, deve ser o FECHADO, orientado pelo quantum de pena cominado, bem como diante da reincidência, não lhe sendo aplicável a substituição da pena, tampouco o sursis penal.

Ante o exposto e considerando tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar o acusado BRUNO CESAR DE ANDRADE, como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

DECLARO, ainda, NALANDA GOMES ALVES DE LIMA e MARCOS VINICIUS DE QUEIROZ LOURENÇO como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.

11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, na forma do §4º do mesmo artigo, razão pela qual os CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em relação a Nalanda Gomes Alves de Lima e a Marcos Vinicius de Queiroz Lourenço, em face da ausência de elementos que justifiquem a imposição de qualquer medida cautelar (art. 282 do CPP), bem como diante da fixação de regime aberto, concedo

aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.

Já no que se refere ao acusado Bruno Cesar de Andrade, entendo que restam mantidos os elementos que justificaram a decretação da tutela cautelar anteriormente deferida e levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, mantenho a sua prisão preventiva.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual, se o caso.

Em razão da origem ilícita do dinheiro apreendido, decreto a perda do numerário e a destinação direta ao FUNAD, nos termos do art. 63 da citada lei, oficiando-se.

No que se refere aos aparelhos celulares, uma vez que não restou demonstrada sua utilização para a prática delitiva, autorizo sua devolução aos acusados, com o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Em relação à droga apreendida, caso a providência ainda não tenha sido tomada, oficie-se à Delegacia de Polícia, determinando sua destruição.

No que se refere aos aparelhos celulares, uma vez que não restou demonstrada sua utilização para a prática delitiva, autorizo sua devolução aos acusados, com o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Acerca dos outros bens apreendidos (fl. 25 - balança de precisão e faca), manifeste-se o Ministério Público.

Servirá a presente como mandado e o ofício, se o caso.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca da condenação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Palmital, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA